

1501502-98.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... é conhecido pela prática de tráfico de drogas e foi detido recentemente. Ele negou o tráfico e falou que era usuário. Em juízo a testemunha disse que a equipe de moto estava em deslocamento, tinham acabado de verificar uma denuncia de trafico do Jardim Europa e foi pago uma ocorrência de perturbação de sossego no Bairro Vila Esperança. Quando desciam a rua Antonio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501502-98.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309885/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21378325 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2691/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2309885 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

DOUGLAS WESLEI PINTO

Artigo da Denúncia:

Art. 329 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do(a) CP e Art. 33 "caput" c/c

Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

10/02/2022

Réu Preso

Em 10 de fevereiro de 2022, às 15:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu DOUGLAS WESLEI PINTO, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Hércules de Souza Bispo OAB 223747/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Juan Gustavo Alonso Franco de Godoi Alfaro e CAINA DAYAN MORAES DA SILVA. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o(a) acusado(a) se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de

São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu DOUGLAS WESLEI PINTO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal, eis que: 1) no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 19h15, na Rua Heleonides Maciel de Meneses, nº 394 - Vila Esperança, nesta cidade e Comarca de Tatui, nas proximidades da E.E. Professor Ary de Almeida Sinisgalli - fls.62, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 10 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 1,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e 2) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos Policiais Militares Juan Gustavo Alonso Franco de Godoi Alfaro e Cainã Dayan Moares da Silva, funcionários competentes para executá-lo. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, permanecia no local da abordagem, aguardando usuários para promover a venda oportuna. Policiais Militares estavam em serviço quando avistaram DOUGLAS na via pública, fazendo contato com o motorista de um veículo, que se evadiu do local quando percebeu a aproximação da viatura, tomando rumo ignorado. De imediato, os policiais efetuaram a abordagem do acusado, que se mostrou muito alterado e, em seu poder, encontraram a importância de R\$ 293,00 em espécie, angariado com a venda de entorpecentes que ele promovia naquele local. Desconfiados, os agentes de segurança pediram para DOUGLAS abrir a boca, quando o denunciado se alterou ainda mais e tentou chamar a atenção de populares que estavam nas proximidades. No entanto, logo em seguida, DOUGLAS cuspiu 10 porções de "crack" que estava escondendo dentro da boca, dispostas em embalagens individuais, de modo a facilitar o comércio ilícito. Ao receber voz de prisão pela prática de tráfico de drogas, o acusado tentou se evadir e ofereceu resistência à prisão, mediante o emprego de violência, passando a agredir os policiais militares, competentes para executar o ato, sendo necessário o uso de algemas e de força moderada para contê-lo. Notificado (fls. 81), o réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 97/103). A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 107/111). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. De outra banda, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio, em razão da ausência de provas da destinação comercial do entorpecente e, em caso de condenação pela capitulação jurídica dada na denúncia, pela concessão de todos os benefícios legais a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 23/24, bem como certidões a fls. 20/22. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta parcial procedência. Primeiro em relação a imputação pela prática do crime previsto no artigo 329, caput do Código Penal, acompanhado a manifestação ministerial, eis que, em que pese presentes os indícios de autoria quando do recebimento da denúncia, nesta data, pela prova colhida em juízo, em especial o depoimento dos policiais, tem-se que o réu tentou fugir no momento de sua abordagem e até mesmo causar certo tumulto, entretanto, não se verifica que o réu tenha praticado qualquer ato de violência. Assim a simples tentativa de fuga, e o ato de esquivar-se do algemamento são insuficientes para caracterização do delito em espécie, eis que urge que o réu

tenha dirigido violência contra a pessoa competente para praticar o ato. Ainda, entendo que, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelas razões que passo a expor. Apesar da majorante em questão ter natureza objetiva e, portanto, dispensar a intenção do traficante de captar sua clientela junto aos frequentadores dos locais elencados no dispositivo legal supra citado, tem-se que, para não gerar responsabilidade penal objetiva, exige-se que haja concentração de pessoas nas proximidades e adjacências daquele lugar para justificar a incidência da causa de aumento especial em tela. Ora, a ratio da norma visa exasperar a pena de pessoa que se aproveita da aglomeração de pessoas nas proximidades daquele local, facilitando a ocultação e evasão do traficante. In casu, como os fatos se deram por volta das 19h15, e o estabelecimento de ensino apontado a fls. 62/64 tem horário de funcionamento diurno e vespertino, até às 17h00, estando, portanto, fechado, não havia concentração de pessoas a justificar a incidência da causa de aumento em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). E ainda, como pontuado pelo Ministério Público nesta oportunidade, verificado pelo "google maps" a distância entre a escola e o local dos fatos, seria de 300 metros, o que extrapola a interpretação de imediações e o critério que vem sendo utilizado por este juízo, de considerar a distância máxima de 200 metros. Informo que a distância trazida no croqui, é medida em linha reta e não corresponde ao exato percurso entre um ponto a outro. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. Quanto a materialidade delitiva, a defesa insurgiu-se contra a apreensão dos entorpecentes, eis que os policiais não tem conhecimento em área química ou outra similar e ainda contra forma e metodologia do laudo pericial que concluir pela existência de substância entorpecente. Não há que se falar em qualquer vício ou mancha quer na apreensão feita pelos policiais que tão só suspeitam da natureza da substância apreendida, encaminhando o produto ao distrito policial, que procederá ao necessário para a devida análise, ou ainda, em falha na metodologia empregada pelo Instituto de Criminalística, instituição pública, sem qualquer fim lucrativo, que goza de presunção relativa de veracidade em seus trabalhos. Aponte-se ainda que a droga é avaliada em dois momentos – no exame de constatação preliminar e após no laudo definitivo. No mais, a autoria é igualmente evidente e

clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 05), afirmou não estava efetuado o tráfico de drogas e que não portava nenhum tipo de entorpecentes. Estava somente passando pelo local e que o dinheiro é do seu trabalho. Não estava vendendo drogas e reclamou dos policiais que lhe prenderam, pois esses lhe bateram e está com dores na perna. Em juízo disse que tinha acabado de ser demitido da empresa Celeni (fabrica de meias) em que trabalhava e recebeu valores. Fuma desde os 14 anos e naquele dia foi comprar entorpecentes. Os policiais o abordaram de forma agressiva e o empurraram para a viatura, começou a gritar para as pessoas verem o que estava acontecendo, pois ele estava ali para comprar para seu uso. Tinha acabado de fumar uma porção de crack e por isso estava descontrolado. Quanto ao veículo, não pegou nada de ninguém de veículo, pegou de uns meninos que estavam mais abaixo. Pagou dez reais a porção. Pegou um cigarro no bar e um bic. Fumou direto no bombril e no canudinho. Já tinha descartado isso e saiu andando de bicicleta. Teve passagem na vara da infância e foi para Fundação Casa. Tem 22 anos. Não tem passagem em clinica porque não queria ir, sua mãe já tentou interna-lo. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - resta evidente que o acusado negou a prática dos crimes lhe imputados, o que foi afastado pela prova oral produzida. De fato, o Policial Militar Juan Gustavo Alonso Franco de Godoi Alfaro, em sede policial (fls. 03), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em deslocamento para atender uma ocorrência de perturbação de sossego, quando, pelo Bairro Vila Esperança, local bem conhecido pela prática de tráfico de drogas, avistaram o acusado fazendo contato com um veículo. Aproximaram-se e o veículo saiu do local, mas não conseguiram anotar o emplacamento. O acusado estava de costa e foi abordado. O acusado ficou alterado e foi feito a revista pessoal realizada pelo SD PM Dayan, o qual encontrou R\$ 293,00 no bolso. Foi solicitado que o acusado abrisse a boca e ele começou a ficar alterado querendo chamar a atenção dos demais populares. Então, o acusado começou a cuspir para fora 10 pedras de crack que estavam debaixo de sua língua. Foi dado voz de prisão e o réu tentou se evadir do local e começou a resistir, sendo necessário o uso de força física moderada para conte-lo e algemá-lo. O acusado é conhecido pela prática de tráfico de drogas e foi detido recentemente. Ele negou o tráfico e falou que era usuário. Em juízo a testemunha disse que a equipe de moto estava em deslocamento, tinham acabado de verificar uma denuncia de trafico do Jardim Europa e foi pago uma ocorrência de perturbação de sossego no Bairro Vila Esperança. Quando desciam a rua Antonio Pereira Fiuzza na rua Heleonides visualizaram o réu numa bicicleta fazendo contato com um veículo. O veículo saiu do local mas o réu acabou por ser abordado. O réu havia colocado algo em sua boca, e estava exaltado, criando tumulto e instado a jogar o que estava em sua boca ele jogou as porções de droga. O réu impedia o algemamento querendo correr para rua Antonio Pereira Fiuzza, não querendo ser segurado e acabou sendo levado ao chão e algemado. Convergingo em mesmo sentido, o também Policial Militar Caina Dayan Moares da Silva, em solo policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em deslocamento para atender uma ocorrência de perturbação de sossego e visualizaram Douglas conversando com alguém em um carro. Abordaram o réu, ele demonstrou nervosismo, no bolso foi encontrado R\$293,00 e seu parceiro percebeu que ele falava enrolado e pediu para ele abrir a boca, local em que viram as porções de crack. O réu expeliu as pedrinhas, disse que era usuário, começou a criar tumulto para atrair populares. O réu saiu correndo, e foi necessário algemá-lo para conte-lo. O réu é conhecido dos meios policiais. O réu não aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente e não trazia consigo nenhuma apetrecho destinado ao uso da droga. O réu disse que trabalhava mas não deu maiores informações acerca do dinheiro. Foi possível concluir que o réu entregava algo para o individuo que estava dentro do carro. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam

incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos das agentes de segurança, que narraram verossimilmente, a apreensão de drogas em poder do réu, mais precisamente na boca dele; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a localização do acusado em local conhecido nos meios policiais, assim como o réu, pela prática do tráfico de drogas; 4) o comportamento suspeito do acusado, que ficou muito alterado quando os policiais pediram para abrir a boca, onde ocultava drogas; e 5) a não apreensão de instrumentos destinados ao consumo de crack, como “cachimbo”. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard,

RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 83/85) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, trata-se de réu reincidente, mas essa circunstância será apreciada em segunda fase, razão pela qual, por ora, fixo sua pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, faz-se presente a circunstância agravante de reincidência, que, aliás, é específica (fls. 20 – P nº 0000430-58.2018.8.26.0571), agravando sua pena em 1/5, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se trata de réu reincidente, não estando, assim, preenchidos todos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da benesse. No mais, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33 do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a reincidência, inclusive específica, do réu, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu. A mesma motivação acima

exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, condenar o réu DOUGLAS WESLEI PINTO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além da imposição 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, e absolve-lo pela imputação como incurso no artigo 329, caput do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando a reincidência, que aliás é específica, e Maus antecedentes do acusado, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. E não se venha alegar a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 ("coronavírus"). Trata-se de tema que reclama prudência judicial no exame das medidas cautelares pessoais, em especial, as prisões preventivas e temporárias. Isso porque, se é fato que as aglomerações de pessoas podem acelerar o contágio da doença e sua disseminação, também é verdade que a libertação indiscriminada dos presos, além de implicar indiscutível prejuízo à manutenção da segurança pública e da aplicação da lei penal (já que há o indiscutível risco de, em tese, praticar novos delitos ou por-se em fuga), também poderá propiciar, por esse fluxo acentuado de pessoas, maior transmissão da enfermidade. É dizer, pode ser que o preso, agora libertado, já esteja infectado, mas em quadro assintomático (o que, segundo dados científicos, pode demorar até 2 semanas ou nem mesmo se manifestar), o que proporcionará a infecção de seus familiares e outras pessoas com quem tiver contato. Outrossim, em estabelecimentos prisionais, onde o acesso de pessoas é controlado e, por ora, proibido, há menor probabilidade ser contaminado do que, em liberdade, saindo as ruas, onde não se tem controle sob a mobilidade

dos cidadãos. Dito de outro modo, se a intenção é preservar a saúde do preso, é possível que, em liberdade, por não haver restrição e/ou controle de sua mobilidade, tenha maior possibilidade de contrair a doença do que preso, onde o acesso de pessoas é restrito e, por ora, proibido. O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisados outras peculiaridades do caso concreto. In casu, os elementos acima apontados denotam que é o caso de manutenção da prisão preventiva, o que não se altera com a situação de calamidade pública gerada pelo coronavírus. Até porque não se tem notícia de preso infectado na unidade prisional do acusado, que esse se encontra enfermo, tampouco que integra grupo de risco. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 293,00 em dinheiro – conforme depósito judicial a fls. 89), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse

em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 93). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA